

1501105-41.2022.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Maria Letícia Pozzi Buassi

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... no sentido de evidenciarem ter o acusado praticado o tráfico ilícito.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do tráfico para a formação do Juízo de certeza, bastando a comprovação pelos elementos que cercam o agente. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501105-41.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501105-41.2022.8.26.0559

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEBER DAMASCENO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

WEBER DAMASCENO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, e no art. 35, caput, c. c. o art. 40, inc. III, todos da Lei nº 11.343/06; e no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, combinados na forma do caput do art. 69 do Cód. Penal.

Consta que no dia 30 de junho de 2022, por volta das 11h45min, na Rua Francisco Alves de Andrade, 49, nesta cidade e comarca, nas imediações de estabelecimento de ensino, transportava e trazia consigo, o réu, para futura entrega a terceiros, uma porção de "maconha", pesando 7,56g, substância esta entorpecente e determinante de dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de portar um aparelho celular e R\$ 1.469,00.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, portava, o réu, uma arma de fogo

calibre 32 "Taurus", de uso permitido, municida com um cartucho íntegro e quatro picotados, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narra, ainda, a inicial, ter se associado, o réu, a indivíduos não identificados, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas. Policiais militares, em patrulhamento de rotina, perseguiram e abordaram o réu, que tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, localizando-se, em revista pessoal, o revólver municido, o celular, o dinheiro e a porção da droga. Oferecida a denúncia foi o réu notificado e apresentou defesa prévia. Recebida a denúncia designou-se audiência de instrução, na qual foram ouvidas duas testemunhas comuns e uma apontada pela defesa. Após, foi interrogado o réu. Em alegações finais via memoriais, o representante do Ministério Público, sustentando demonstradas a materialidade dos fatos e a autoria dos delitos, requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 185/195). A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu apontando, em suma, insuficiência de provas a delinear os crimes (fls. 199/221). É o relatório. DECIDO.

Por primeiro, não há nulidade na abordagem policial, tampouco qualquer indicativo de abuso de autoridade, por parte dos agentes. Isso porque, é dever da polícia ostensiva, com base em protocolos pré-existentes e de rígida elaboração, fundados, inclusive, na experiência pessoal, averiguar situações de desrespeito à ordem jurídica e social. Ademais, in casu, não se observa qualquer indicação de violação de direitos do réu, que tentou fugir, motivando o desfecho da diligência policial, a qual, registre-se, obedeceu às normas legais pertinentes. Afastada a preliminar, passo à análise do mérito. A materialidade dos fatos vem comprovada por intermédio do auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, que revela o encontro do entorpecente, do celular, do dinheiro, da arma e das munições em tela. Há, ainda, o laudo de constatação de fls. 23/25 e o laudo de exame químico toxicológico de fls. 65/67, concludentes no sentido de se tratar de Tetrahidrocannabinol - THC, a substância encontrada. A balança foi periciada (fls. 147/149). A vistoria na arma e nas munições apontou a eficácia na realização de disparos (fls. 84/90). O aparelho celular foi analisado fls. 177/181. Na fase policial, exerceu o réu a prerrogativa constitucional de permanecer calado. Em Juízo, falou o réu que transportava "maconha" adquirida para consumo. Esclareceu a compra da arma, para defesa pessoal. Contam os policiais terem, em patrulhamento, abordado o réu, o qual tentou fugir e se esconder no interior da escola infantil "Célia Honsi de Melo", ao notar a viatura, localizando-se, nas vestes, uma porção de "maconha", o celular, o revólver, as munições e o dinheiro, em notas diversas. Para tais testemunhas, admitiu, o réu, a negociação de entorpecentes, tanto que portava dinheiro proveniente do gerenciamento de pontos de tráfico. Assegurou, ainda, o réu, ser proprietário da arma apreendida, utilizada para defesa pessoal. Explicaram os agentes, com congruência de informações, cada conduta do réu e a forma de embalagem do produto ilegal, além de detalhes outros da diligência, relevantes para a questão. Vale lembrar que o fato de policiais que participam de diligências serem testemunhas sobre estas, torna o relato apresentado mais rico em detalhes e, por isso, mais digno de fé. No caso em tela as declarações apresentaram-se de forma harmônica e coesa com o restante da prova, razão pela qual não podem ser desconsideradas, inexistindo qualquer motivo para que quisessem, os policiais militares, incriminar o réu ou forjar os crimes. A jurisprudência é uníssona ao reconhecer a validade das declarações prestadas, em

juízo, por policiais. Neste sentido o Supremo Tribunal Federal: “o valor do depoimento pessoal dos servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73.518/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.03.2011).

A testemunha ouvida em nome da defesa nada acrescentou ao deslinde da questão.

Urge consignar ser grande a quantidade de droga apreendida em comparação à condição financeira do réu, que não comprovou relação atual de emprego, logo, seria imprópria somente a eventual uso, sendo a negociação ou guarda do produto, medida impositiva na situação.

Como não se produziu prova a contrariar o já citado auto de exibição e apreensão, o tráfico é consequência lógica das provas colhidas.

Dessa forma, verifica-se não existirem apenas indícios de prova, mas sim clareza e harmonia entre elas, no sentido de evidenciarem ter o acusado praticado o tráfico ilícito.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do tráfico para a formação do Juízo de certeza, bastando a comprovação pelos elementos que cercam o agente. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. 6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente” –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso” (STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Importa destacar não ter a defesa delineado, de forma cristalina, a apresentação, por agentes, de tóxico não achado na posse do réu, e nem motivo haveria para tanto. Por isso tal versão é indigna de crédito.

A análise conjunta das circunstâncias apresentadas leva à conclusão de ter o réu, portanto, praticado os ilícitos em testilha, quais sejam, a venda de entorpecente, em associação, com porte ilegal de arma.

Não há dúvida no sentido de dividir réu e indivíduos não identificados, as atribuições para que o tóxico fosse comercializado, ou seja, associados, fornecia o denunciado a droga, comercializada em diversos pontos, pelos comparsas, sendo ele o responsável pelo recolhimento do dinheiro obtido nesta atividade, conforme admitido durante a abordagem policial.

Emerge das provas apresentadas exercer o denunciado e outros indivíduos, atividades essenciais para a negociação ilegal, ou seja, havia vínculo associativo entre eles, uma predisposição comum de meios para o crime de tráfico de droga.

A unanimidade da prova revelou, também, a ocorrência da causa de aumento da pena relativa ao fato de negociar, o réu, entorpecente próximo a local de prática

estudantil, tanto que tentara se esconder nas dependências da escola, conforme relato dos policiais.

Importante destacar que o tráfico de drogas, efetivado nas imediações de estabelecimentos de ensino, é fato suficiente para a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III da Lei 11.343/2006.

Neste sentido: "(...) A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já decidiu que o tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local" (STF, HC 208.654/PR, Rel. Min. Nunes Marques, 11.04.2022).

Além disso, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, caberia à defesa a prova da existência de registro da arma e das munições, bem como de autorização para o réu mantê-las sob guarda, o que não aconteceu, logo, outra explicação não há, exceto ter o réu praticado o crime em estudo.

Em outras palavras, a análise das provas aponta, com a certeza necessária, ter o réu mantido, sob guarda, arma e munições sem o devido registro e porte.

Não há como consentir, ainda, que se valha o réu, de meios ilegais, no caso, uso de arma irrestrita, como forma de garantir a própria segurança. Tinha o acusado a alternativa de agir legalmente, mediante aquisição de arma de fogo registrada, com a devida documentação e autorização para o porte.

Convencida da responsabilidade penal do réu, passo a individualizar as penas.

- art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por não ostentar maus antecedentes.

Deixo de aplicar a menoridade do acusado, circunstância atenuante contida no art. 65, inc. I, do Cód. Penal, por já ter fixado a pena-base no mínimo legal.

Em face da causa especial de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei n.º 11.343/06, pois o tráfico foi realizado nas imediações de entidade estudantil, elevo a pena em 1/6 (um sexto), o que perfaz 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

- art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, por não ostentar maus antecedentes.

Deixo de aplicar a menoridade do acusado, circunstância atenuante contida no art. 65, inc. I, do Cód. Penal, por já ter fixado a pena-base no mínimo legal.

Com a causa especial de aumento, prevista no inciso III do art. 40 da Lei n.º 11.343/06, pois foi o tráfico realizado nas imediações de entidade estudantil, elevo a pena em 1/6 (um sexto), o que perfaz 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

- art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por não ostentar maus antecedentes.

Deixo de aplicar a menoridade do acusado e a confissão da autoria, circunstâncias atenuantes contidas no art. 65, incs. I e III, "d", do Cód. Penal, por já ter fixado a pena-base no mínimo legal.

Com base no caput do art. 69 do Cód. Penal, a pena totaliza 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 1.409 (mil quatrocentos e nove) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão é o fechado (art. 1º, § 1º, da Lei n.º 11.464/07).

Destaco que quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena do réu, já se considerou o período de prisão provisória, nos termos do § 2º do art. 387 do Cód. Proc. Penal.

O fato de ter o réu respondido encarcerado à instrução do feito não implica, com a

prolação desta sentença, na concessão de regime menos gravoso. Neste sentido: "(...) PENA. DETRAÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ART. 387, § 2º, DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.736/12. FIXAÇÃO A SER EFETUADA PONDERANDO-SE CONJUNTAMENTE O QUANTUM DA PENA APLICADA COM AS CONDIÇÕES SUBJETIVAS PREVISTAS NOS ARTS. 33, § 3º E 59 DO CP. ENTENDIMENTO. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença". (TJSP, Apelação Criminal nº 1500199-27.2019.8.26.0407, Rel. Des. Grassi Neto, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 19/11/2020). Ainda: "Descabe, igualmente, pleitear aqui regime prisional mais brando com base na atual redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o que ora se destaca, quer à luz do invocado princípio da suficiência da sanção, quer porque a consideração do tempo de prisão provisória não prescindiria de demonstração cabal de bom comportamento carcerário e de condições subjetivas favoráveis, tal como se exige para a avaliação do cabimento de progressão. Se assim não fosse, ficaria ferida de morte a lógica do sistema penal. E tal demonstração não existe nos autos." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500128-92.2021.8.26.0559, Rel. Fátima Gomes, 9ª Câmara de direito Criminal, julgado em 31.03.2022).

Deixo de aplicar o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porque a quantidade da droga apreendida e o concurso de delitos, indicam dedicar-se o réu à atividades criminosas, posto inexistir comprovação atual de relação de emprego.

Neste sentido a doutrina: "de mais a mais, tem-se decidido que apreensão de grande quantidade de drogas (bem como a diversidade da natureza dos entorpecentes encontrados), a depender das peculiaridades do caso concreto, é circunstância hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, conseqüentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo do narcotráfico, ainda que ele seja primário e não possua maus antecedentes. Dessarte, a priori, a circulação de expressiva quantidade de entorpecentes pelo agente evidenciará sua habitualidade delitiva e, por isso, fundamentará o afastamento da causa de diminuição de pena." (MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius, Lei de Drogas: aspectos penais processuais. 2021, p. 107).

O valor unitário do dia-multa é o mínimo legal, considerada a situação econômica do acusado (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno WEBER DAMASCENO, R.G. n.º 60.210.768, a 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.409 (mil quatrocentos e nove) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, por ter infringido o art. 33, caput; o art. 35, caput, c. c. o art. 40, inc. III, todos da Lei nº 11.343/06; e o art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, combinados na forma do caput do art. 69 do Cód. Penal.

Não poderá o réu apelar desta sentença em liberdade, nos moldes do art. 1º, § 3º, da Lei nº 11.464/07.

Ainda que assim não fosse, em sendo necessária a prisão no correr da instrução do feito, a prolação desta sentença condenatória apenas reforça os motivos ensejadores do afastamento do réu do convívio social, por garantia da ordem pública.

Recomende-se o réu no presídio onde se encontra, expedindo-se mandado de prisão, se necessário.

A pena pecuniária será atualizada a partir da data do fato, uma vez que a correção monetária não apresenta nenhum plus, mas sim tentativa de reposição do poder aquisitivo da moeda.

Força concluir ainda, que a multa não corrigida perde o caráter aflitivo, tornando inútil a imposição, inatendidas as finalidades da sanção penal de punição, dissuasão e reeducação do delinquente.

Observados o art. 63 da Lei nº 11.343/06 e o art. 91, inc. II, "b", do Cód. Penal, DETERMINO O PERDIMENTO do dinheiro e do celular (fls. 14/15), pois obtidos em razão do comércio ilícito. Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, oficie-se à Autoridade Policial para que se proceda a destruição das amostras de entorpecente guardadas para contraprova.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

P.R.I.C..

São José do Rio Preto, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA